



Roj: **STS 3445/2025 - ECLI:ES:TS:2025:3445**

Id Cendoj: **28079130022025100163**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **10/07/2025**

Nº de Recurso: **6594/2022**

Nº de Resolución: **945/2025**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ M 7749/2022,**
ATS 1586/2024,
STS 3445/2025

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 945/2025

Fecha de sentencia: 10/07/2025

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 6594/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 24/06/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

Transcrito por: AFJ

Nota:

R. CASACION núm.: 6594/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 945/2025

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Francisco José Navarro Sanchís, presidente

D. Isaac Merino Jara

D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

D. Manuel Fernández-Lomana García

D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

D.^a Sandra María González de Lara Mingo

En Madrid, a 10 de julio de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por el procurador don Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros en representación de VILLIERS ACTIONS EUROPE MIROVA, contra la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 2021 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso número 360/2020, interpuesto contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 29 de enero de 2020, en relación con la liquidación provisional del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento.

Ha sido parte demandada la Administración General del Estado, representada por el abogado del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El objeto del presente recurso de casación lo constituye la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 2022 por la Sección Quinta de la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 29 de enero de 2020, por la que se resuelven las reclamaciones económico-administrativas número nº 28-22512-2016, 28-22514-2016, 28-22517-2016, 28-22593-2016 y 28-22597-2016, interpuestas por el concepto de Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ejercicio 2012, contra el acuerdo de liquidación provisional, cuyo Fallo decía: «*[Q]ue, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad Villiers Actions Europe Minova contra resolución de 29/01/2020, dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid que de manera acumulada desestimó las reclamaciones económico administrativas 28/22512, 22514, 22517, 22593 y 22597/2016, interpuestas respectivamente contra las liquidaciones provisionales en concepto de Impuesto sobre la renta de no residentes de 2012, referencia 201221091661559N, 201221091661551F, 201221091661561K, 201221091661552E y 201221091661558C, por ser ajustada a derecho la resolución recurrida. Se hace expresa imposición de costas a la parte recurrente [...]*».

SEGUNDO.-Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de la entidad VILLIERS ACTIONS EUROPE MIROVA se presentó escrito preparando recurso de casación, ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se tuvo por preparado mediante auto de dicha Sala de fecha 5 de septiembre de 2022, emplazando a las partes personadas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por plazo de 30 días.

TERCERO.-Mediante auto dictado el 12 de febrero de 2024 por la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se admitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 16 de junio de 2022 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se acordó la remisión de las actuaciones para su tramitación y decisión a la Sección Segunda de este Tribunal.

La representación procesal de la entidad recurrente interpuso recurso de casación en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de fecha 19 de febrero de 2024, que concluye solicitando «*[q]ue tenga por presentado este escrito y por interpuesto recurso de casación contra la Sentencia dictada con fecha 16 de junio de 2022 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid y, previos los trámites oportunos, dicte Sentencia por la que anule íntegramente la Sentencia impugnada y los actos administrativos por ella confirmados y, en definitiva, reconozca el derecho a la devolución instada por mi representado junto con los correspondientes intereses de demora [...]*».

CUARTO.-Dado traslado para oposición a la Administración General del Estado y transcurrido el plazo conferido se le tuvo por decaído en su derecho, presentando escrito el 3 de junio de 2024, el cual se admitió en virtud del artículo 128.1 LJCA en el que solicitaba que «*[P]or las razones expuestas consideramos que la sentencia recurrida es ajustada a Derecho, y solicitamos su confirmación, con desestimación del recurso interpuesto de contrario [...]*».

QUINTO.-De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de esta Jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública, mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de junio de 2024, quedaron las presentes actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.

Mediante providencia de fecha 23 de mayo de 2025, se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos y se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 24 de junio de 2025, fecha en que comenzó su deliberación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resolución impugnada y antecedentes relevantes

1.1.-Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta del 16 de junio de 2022, por la que se desestimó el recurso 360/2020, que Villiers Actions Europe Mirova dedujo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 29 de enero de 2020, por la que desestimó las reclamaciones económico-administrativas núm. 28/22512/2016, 28/22514/2016, 28/22517/2016, 28/22593/2016 y 28/22597/2016, interpuestas contra acuerdos de liquidación provisional por el concepto del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), ejercicio 2012, por importes de 24.663,24; 25.893,91; 93.273,85; 49.144,16 y 30.925,98 euros respectivamente.

La sentencia reproduce lo que dijo la Sala de instancia en otro pronunciamiento anterior del 21 de julio de 2021, recurso 1556/2019, que a su vez se remitía al de 16 de julio de 2020.

1.2.-En síntesis, el origen de la disputa se centraba en si era aplicable la tributación del 1% del artículo 28 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), al fondo de inversión colectiva no armonizado francés, no sometido a la Directiva 2009/65/CE, para el que se reclamaba la aplicación de los criterios de comparabilidad y equivalencia suficientes, y que le fueron denegados.

SEGUNDO.- Cuestión de interés casacional

Por auto del 12 de febrero de 2024, se fija como cuestión de interés casacional «[2.1.] *Determinar si el análisis de comparabilidad entre Fondos de Inversión Libres o no armonizados no residentes (FIL o Hedge Fund) y las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) residentes en España, al objeto de aplicar el artículo 63 TFUE, debe realizarse conforme a la legislación española de fuente interna aplicable a los fondos de inversión libre, conforme a la Directiva 2009/65/CE, o conforme a la legislación aplicable a este tipo de Fondos de Inversión Libres en el Estado de residencia (o Estado de origen).*

2.2. *Precisar qué parámetros deben tenerse en consideración a efectos del análisis de comparabilidad entre Fondos de Inversión Libres o no armonizados no residentes (FIL o Hedge Fund) y las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) residentes en España, en particular, si debe tenerse en cuenta la existencia de autorización previa de la constitución del Fondo de Inversión Libre no armonizado y su mantenimiento en el tiempo, número de partícipes, patrimonio o capital social mínimo, carácter abierto del Fondo permitiendo el acceso a cualquier inversor, objeto de las inversiones, diversificación de riesgos y el diferimiento de la tributación de todo tipo de rentas obtenidas por la IIC hasta el momento de su llegada efectiva a los partícipes o inversores finales.*

2.3. *Aclarar a quién corresponde la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos de comparabilidad, y, en particular, de que en su caso se ha neutralizado el trato discriminatorio por el eventual juego de lo dispuesto en el Convenio bilateral suscrito entre España y el país de residencia del Fondo de Inversión Libre, que determine que el fondo reclamante haya podido deducir en su país de residencia la tributación soportada en España, neutralizando así los efectos de la restricción a la libre circulación de capitales. [...]*».

Se identifican como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación, los artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; los artículos 13.1.f), 14.1.1), 25, 31.2 y 58 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes; el artículo 10 del Convenio entre el Reino de España y la República de Francia a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995; el artículo 28.5 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; el artículo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- Alegaciones de las partes

3.1.-Afirma la representación procesal de Villiers Actions Europe Mirova que se trata de un fondo de inversión no armonizado o de inversión libre no incluido en el ámbito de la Directiva 2009/65/CE, al que le son plenamente aplicables, por comparabilidad, los criterios previstos para los fondos de inversión libre españoles regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, así como en su reglamento aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.

El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) impone, respecto de los dividendos percibidos de sociedades, la aplicación del mismo tipo impositivo previsto en la normativa interna para las entidades comparables residentes en España, por lo que todo lo que exceda del 1% previsto por la norma española constituye un ingreso indebido.

Recuerda que son de aplicación los pronunciamientos de esta Sala a los que ya se refiere el auto de admisión.

(i) En cuanto a la carga de la prueba de los criterios de comparabilidad, y a falta del marco jurídico interno que lo desarrolle junto con los criterios de devolución para aplicar el artículo 63 TFUE, es necesario hacer una abstracción tanto de la normativa española como de la legislación del Estado de residencia del fondo y definir un marco normativo objetivo ajeno a las particularidades nacionales. En este sentido, la disposición adicional tercera, apartado 1 c), del Reglamento IRNR, establece las condiciones para que las IIC alternativas se beneficien de la exención en el pago de intereses a residentes en la UE, y basta con la acreditación de que están sometidas a un régimen de autorización, registro o supervisión administrativa y gestionadas por gestoras de fondos de inversión alternativos reguladas por la Directiva 2011/61/UE, como ocurre con la actora. La comparabilidad debe realizarse entre la norma española, la francesa y el marco de la UE. En definitiva, bastará con que el fondo intente acreditar seria y rigurosamente la equivalencia con sus homólogos residentes para que la carga de la prueba se entienda desplazada hacia la Administración.

La sentencia de instancia concluye que la documentación aportada por la actora no tiene valor probatorio a los efectos de acreditar que cumple los requisitos de la normativa española y únicamente toma como referencia los requisitos impuestos por la regulación española de las IIC, lo que provoca una equivocada identidad entre las residentes y no residentes, cuando debería haberse centrado en valorar si se trataba de categorías equivalentes. En este sentido, la recurrente acreditó los extremos necesarios para aplicar los criterios de comparabilidad y aportó (a) el prospecto con la información publicada para los inversores; (b) el certificado de residencia fiscal en Francia; (c) el extracto de la legislación francesa que le resultaba de aplicación; y (d) una copia del certificado emitido por la AMF (Autoridad de los Mercados Financieros) que acreditaba que es un fondo registrado bajo el *Code Monétaire et Financier* con naturaleza jurídica de fondo de inversión no armonizado.

(ii) Sobre la prueba de la neutralización del trato discriminatorio y de la restricción a la libre circulación de capitales, la sentencia de instancia no analiza las consecuencias de una eventual neutralización de la restricción de la libertad de capitales soportada por la recurrente ni las consecuencias que tiene.

La carga de la prueba para acreditar que esa neutralización ha sido íntegra recaería, en todo caso, sobre la Administración, como han reconocido las STS 19 de marzo de 2018, RC 2070/2017; 20 de marzo de 2018, RC 2522/2017; 6 de junio de 2019, RC 2067/2017; o 19 de mayo de 2020, RC 6312/2017.

3.2.-El abogado del Estado se ciñe, para oponerse al recurso, a la doctrina recogida por esta Sala.

Afirma que no se ha probado el primero de los elementos determinantes de la comparabilidad. No ha acreditado que se trate de entidades que capten las aportaciones de capital del público en general, sin que puedan tener tal consideración aquellas entidades que limiten el acceso a patrimonios familiares o personales, que limiten las condiciones de acceso por requisitos subjetivos tales como la condición de pertenencia a un colectivo determinado (como la de empleado de una empresa o una Administración), o componente de un determinado colectivo. Admite el certificado de la AMF de cara a justificar los elementos de comparabilidad censados por las sentencias FIL, pero no se justifica la captación de fondos genérica ni la inexistencia de restricciones o condiciones subjetivas de los partícipes.

El artículo L 214-26-1 del *Code Monétaire et Financier* francés establece que el reglamento o los estatutos de los fondos de inversión alternativos podrán reservar la suscripción o la adquisición de las participaciones o acciones a un máximo de 20 inversores o a una categoría de inversores cuyas características se definan con precisión en el folleto. Se distingue entre los fondos de inversión alternativos *dédié* (dedicado), frente a los fondos de inversión alternativos de *tous souscripteurs* (de todos los suscriptores). Esta circunstancia no ha sido acreditada por la recurrente. En este sentido, en el expediente electrónico correspondiente a la reclamación económica-administrativa 28/22512/2016, se encuentra un folleto, aportado en su día por la recurrente, que indica que la suscripción de las participaciones está específicamente reservada a *LIRCANTEC*, en contestación a un requerimiento de información presentado por la representación de la actora a la AEAT.

Solicita la integración de los hechos en virtud del artículo del artículo 93.3 de la LJCA, con la documental en la que se acredita que Villiers Actions Europe Mirova no es una institución de inversión colectiva sino un instrumento inversor exclusivo de una entidad determinada.

(ii) En cuanto a la carga de la prueba de la comparabilidad, conforme a la doctrina de esta Sala, le corresponde a la FIL no residente acreditar que reúne todos y cada uno de los elementos de comparabilidad, sin que le puedan resultar desproporcionados o extraordinariamente difíciles. En caso de dudas, la Administración deberá acudir a los mecanismos de intercambio de información previstos en los Convenios. No estamos ante una inversión de la carga de la prueba, y menos en este caso donde falta la acreditación del carácter colectivo de la institución. En este caso, la aportación del folleto revela una limitación radical de los sujetos que pueden hacer aportaciones al capital o patrimonio, hasta el punto de ser instrumento de un único inversor.

CUARTO.- Respuesta de la Sala

4.1.- Como advierte el auto de admisión, este recurso se presenta en términos análogos a los resueltos por esta Sala, entre otras, en las sentencias de 5 de abril de 2023, RC 7260/2021; 11 de abril de 2023, RC 7123/2021 y 8220/2021. En el fundamento jurídico decimosexto de la primera de las citadas, reiterado por las posteriores, fijábamos como doctrina jurisprudencial «[1.] *La legislación del Reino de España infringe la libertad de circulación de capitales al establecer un tratamiento diferenciado no justificado entre FIL residentes y FIL no residentes en situaciones comparables, ya que reserva a los FIL residentes un tratamiento fiscal significativamente más favorable, con tributación al tipo de gravamen del 1 por ciento, en tanto los FIL no residentes tributan al tipo impositivo del 19 por ciento, o al que pueda establecer el CDI que en este caso es del 15%, cuando en ambos casos, FIL residentes y no residentes, al percibir rentas consistentes en dividendos de sociedades residentes, incurren en una manifestación de capacidad económica idéntica, que gravan tanto el Impuesto de Sociedades como el Impuesto sobre la Renta de los No residentes.*

2. *Ante la infracción originaria del derecho de la Unión Europea en que incurre la normativa española al imponer como elemento diferenciador del tratamiento tributario la residencia en España, el análisis de comparabilidad entre Fondos de Inversión Libre o no armonizados no residentes ["FIL o Hedge Fund"] y los Fondos de Inversión Libre no armonizados residentes en España, como medio para restablecer la efectividad de la libre circulación garantizada por el art. 63 TFUE, debe realizarse sobre la base de los elementos esenciales intrínsecos considerados por el legislador español para otorgar el tratamiento fiscal más beneficioso a los FIL residentes, interpretados conforme a las disposiciones del Derecho de la Unión Europea reguladoras de la gestión de los Fondos de Inversión Libre, constituida actualmente por la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, así como por la legislación aplicable a este tipo de Fondos de Inversión Libre en su estado de residencia (o Estado de origen).*

3. *En cuanto a los elementos concretos que deben tomarse en consideración a efectos del análisis de comparabilidad entre Fondos de Inversión Libre o no armonizados no residentes ["FIL o Hedge Fund"] y sus comparables residentes en España, son:*

a) *que se trate de entidades que capten las aportaciones de capital del público en general, sin que puedan tener tal consideración aquellas entidades que limiten el acceso a patrimonios familiares o personales, o que limiten las condiciones de acceso por requisitos subjetivos tales como la condición de pertenencia a un colectivo determinado como la de empleado de determinada empresa o administración, o componente de un determinado colectivo. No resulta relevante, en este sentido, que se limite el acceso a inversores que reúnan la condición de inversor profesional o a que se acredite un determinado nivel de formación y conocimiento del funcionamiento de los mercados de valores basado en elementos como el importe mínimo de inversión, dado que el nivel de riesgo que pueden asumir los FIL excede del que con carácter general pueden asumir las IIC armonizadas, y que con ello no se desvirtúa el requisito de constituir un instrumento de inversión colectiva abierto.*

b) *que cuenten con autorización vigente de funcionamiento en su país de origen o residencia, expedido por la autoridad competente para el control y supervisión de las Instituciones de Inversión Colectiva.*

c) *que acrediten que están gestionados por una entidad, autorizada a su vez en su país de origen o residencia, como Gestor de Fondos de Inversión Alternativa (GFIA), en los términos de la Directiva 2011/61/UE que homogeneiza el régimen de los gestores de los FIA.*

d) *La carga de la prueba de que se cumplen los requisitos de comparabilidad establecidos anteriormente corresponde al FIL no residente, si bien en ausencia de una normativa nacional española que determine los concretos medios de prueba que debe aportar, no pueden ser requeridos medios de prueba o certificados que sean absolutamente conformes con los que se exigirían a los FIL residentes en España o que resulten desproporcionados o extraordinariamente difíciles de conseguir. La autoridad administrativa española, cuando dude motivadamente del satisfactorio grado de acreditación, deberá utilizar activamente las facultades de*

obtención de información de que disponga en virtud del Convenio sobre Doble Imposición o instrumento convencional análogo suscrito con el país de origen o residencia del FIL no residente, así como los mecanismos de intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad existentes en el Derecho de la Unión Europea, en particular la Directiva 2011/61/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. La falta injustificada de utilización de estos mecanismos de intercambio de información disponibles para la Administración debe valorarse en la distribución de la carga de la prueba, y, en su caso, permitirá que se considere suficiente la aportada de forma seria y rigurosa por el FIL no residente para acreditar todos y cada uno de los elementos de comparabilidad.

e) La neutralización de los efectos de la restricción a la libre circulación de capitales producida en la legislación nacional tan sólo se podrá considerar alcanzada por el efecto de las previsiones de los Convenios de Doble imposición en aquellos casos en tales disposiciones permitan que el impuesto retenido en origen en aplicación de la normativa nacional pueda deducirse del impuesto debido en el otro Estado miembro hasta el límite de la diferencia de trato a que da lugar la normativa nacional. [...].»

4.2.-Con esta remisión, damos cumplida respuesta al debate suscitado con plena satisfacción del derecho a la tutela judicial. Como hemos reiterado en varias ocasiones, y por todas en la STS 27 de abril de 2015, FJ 2º, RC 1965/2012, «[l]a tutela judicial efectiva se satisface con la motivación por remisión o in aliunde, siempre que el reenvío se produzca de forma expresa e inequívoca y la cuestión sustancial de que se trate hubiera sido decidida en la resolución a la que se remite, según ha reiterado el Tribunal Constitucional en la sentencia 144/2007 (FJ 3º) «[d]entro de las modalidades que puede revestir la motivación hemos afirmado que la fundamentación, por remisión o aliunde-técnica en virtud de la cual se incorporan a la resolución que prevé la remisión los razonamientos jurídicos de la decisión o documento a la que se remite (ATC 207/1999, de 28 de julio , FJ 2)- "no deja de serlo ni de satisfacer la exigencia constitucional contenida en el derecho fundamental" a la tutela judicial efectiva (entre otras muchas, SSTC 187/2000, de 10 de julio, FJ 2 ; 8/201, de 15 de enero, FJ 3, in fine ; 13/2001, de 29 de enero, FJ 2 ; 108/2001, de 23 de abril, FJ 2 ; 5/2002, de 14 de enero, FJ 2 ; 171/2002, de 30 de septiembre , FJ 2; y ATC 194/2004, de 26 de mayo , FJ 4 b; en términos similares, SSTC 115/2003, de 16 de junio, FJ 8 ; 91/2004, de 19 de mayo, FJ 8 ; 113/2004, de 12 de julio, FJ 10 ; 75/2005, de 4 de abril, FJ 5 ; y 196/2005, de 18 de julio , FJ 3), siempre y cuando dicha remisión se produzca de forma expresa e inequívoca (STC 115/1996, de 25 de junio , FJ 2) y que la cuestión sustancial de que se trate se hubiera resuelto en la resolución o documento al que la resolución judicial se remite (SSTC 27/1992, de 9 de marzo, FJ 4 ; y 202/2004, de 15 de noviembre , FJ 5; y ATC 312/1996, de 29 de octubre , FJ 6). [...].»

QUINTO. Respuesta a las pretensiones de las partes

5.1.-La doctrina que fijamos y la remisión que hacemos nos llevan a la favorable acogida del recurso de casación. En cuanto a las pretensiones que se dilucidaron en la instancia, a pesar de las discrepancias a las que hace referencia el abogado del Estado en su oposición al recurso de casación, no existen diferencias sustanciales con los recursos ya vistos en esta Sala que justifiquen que nos apartemos de lo dicho y resuelto.

5.2.-El abogado del Estado hace una observación respecto a los destinatarios del fondo, cuestionando que se dirija a una pluralidad de inversores, lo que le apartaría de los criterios de comparabilidad necesarios en los términos que ha fijado esta Sala. Concretamente, se refiere al contenido del Anexo VI que fue aportado por el representante en España del fondo en el que, a su juicio, no consta la pluralidad de destinatarios como potenciales inversores.

No compartimos esta aseveración del representante de la Administración. Dice literalmente el Anexo VI, con la traducción aportada que, el fondo tiene como destinatarios «[d]édié à 20 investisseur au plus. Il plus spécifiquement reversé a LINCARTEC [...]». Es definitiva, no se limita a un solo inversor independientemente de que el preferente sea LINCARTEC.

Por otro lado, no podemos obviar el contenido del documento emitido el 25 de noviembre de 2020, por la *Autorité des marchés financiers* (Autoridad de los Mercados Financieros, AMF), en el que se indica y certifica que es un Fondo de inversión «[c]on vocación generalista denominado actualmente VILLIERS ACTIONS EUROPE MINOVA fue autorizado el 6012004 con NÚMERO... y fue constituido con arreglo al Code monétaire et financier (Código monetario y financiero), sus decretos de desarrollo, el Reglamento general de la AMF y su instrucción de aplicación. (...) gestionado por la sociedad gestora de cartera Minova autorizada por la AMF con número [...]».

Por último, el inversor preferente, L INCARTECes, probablemente, el mayor plan de pensiones complementario francés, y se erige en una institución a través de la cual se canalizan las inversiones para el pago de las pensiones de un número indeterminado de beneficiarios. En definitiva, estamos lejos de que concurren las situaciones fácticas en las que, bajo la cobertura de este tipo de fondos, lo que se persiga sea la aplicación de los beneficios de una tributación privilegiada a patrimonios individuales o familiares.



No se cuestionan el resto de los criterios o condiciones de comparabilidad que revelaran que la decisión que ahora tomamos deba diferir o apartarse de las que ya hemos adoptamos en supuestos análogos al que aquí enjuiciamos.

SEXTO.- Costas

Respecto a las costas del recurso de casación, no apreciamos temeridad ni mala fe en ninguna de las partes, por lo que cada parte habrá de soportar las causadas a su instancia, y las comunes por mitad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.4 LJCA. En cuanto a las de la instancia, no ha lugar a hacer imposición a ninguna de las partes, dadas las dificultades jurídicas que suscita la cuestión controvertida, por lo que de conformidad con el artículo 139.1 LJCA, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.-Reiterar la doctrina recogida en fundamentos décimo sexto de la STS de 5 de abril de 2023, RC 7260/2021, reproducida en las posteriores de 11 de abril de 2023, RC 7123/2021 y 8220/2021.

2.-Haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador don Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros en representación de Villiers Actions Europe Mirova contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta del 16 de junio de 2022; sentencia que casamos y anulamos.

3.-Estimar el recurso contencioso-administrativo recurso 360/2020, que la actora dedujo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 29 de enero de 2020, por la que desestimó las reclamaciones económico-administrativas núm. 28/22512/2016, 28/22514/2016, 28/22517/2016, 28/22593/2016 y 28/22597/2016, interpuestas contra los acuerdos de liquidación provisional por el concepto del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, ejercicio 2012, por importes de 24.663,24; 25.893,91; 93.273,85; 49.144,16 y 30.925,98 euros respectivamente. Anulamos la resolución impugnada y las liquidaciones y de la que trae causa, reconociendo el derecho a la devolución, como ingreso indebido, de la diferencia retenida por encima del 1%.

4.-No hacemos imposición de las costas procesales causadas en esta casación ni en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.